

1512485-66.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... guardar e manter em depósito drogas, para tráfico.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512485-66.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512485-66.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216206/2021 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 19536096 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 54/21/371 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA, 2216206 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON ANTONIO LOPES FAGUNDES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

MAICON VINICIUS ALEIXO e MAYCON ANTÔNIO LOPES FAGUNDES estão sendo processados como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tudo c.c. Artigo 29, "caput", do Código Penal, acusados de em data de 10 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Perdizes, 98, Bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios, previamente ajustados, trazerem com eles, cada qual, 01 (uma) porção de maconha, bem como guardavam e mantinham em depósito, para fins de traficância, 159 (cento e cinquenta e nove) porções de "maconha", pesando cerca de 233,0 gramas, substância entorpecente e causadoras de dependência química, em desacordo com determinação

legal.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 189/191).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e interrogado o réu Maicon Vinicius Aleixo. Foi declarada à revelia do acusado Maycon Antônio Lopes Fagundes (fls. 295/296).

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, em concurso material; materialidade e autoria das infrações. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa de Maicon Vinicius pretende a absolvição por falta de provas. Invoca o princípio 'in dubio pro reo'. Também negava a associação para o tráfico, por falta de requisitos típicos subjetivos necessários para imputação do artigo 35 da lei 11.343/2006, o que tornava a conduta atípica. Cita doutrina e jurisprudência.

Alternativamente, pugnou pela desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação, pela primariedade, quer reconhecimento de tráfico privilegiado, regime aberto e recurso em liberdade (fls. 302/318).

Por fim, Maycon Antônio pretende idêntica absolvição, por insuficiência probatória. Não foi confirmada a mercancia no local, não houve flagrante de venda, detenção de usuários ou apreensão de objetos destinados a preparação, embalagem, pesagem da droga etc. O agente desconhecia tal prática, o que configurava erro de tipo, ante a excludente do dolo, inexistia vinculação do réu aos atos descritos na denúncia. Para o caso de condenação, pena mínima, com aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da mesma Lei, se não cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no regime disciplinar mais brando (fls. 324/327).

É o relatório.

DECIDO.

A prova é boa e convincente para embasar a procedência total da denúncia.

Verifica-se dos autos que os réus foram presos em flagrante delito e na fase administrativa Maycon Antônio permaneceu em silêncio (fls. 07).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Perante a autoridade policial, Maicon Vinicius alegou que estava na frente da casa de seu amigo, Gabriel. Maycon Antônio também estava por ali. Apenas tomou conhecimento do nome dele nessa data. Em dado momento, Gabriel começou a gritar "olha os homem da civil aí", todos saíram correndo. Sem saber o que estava ocorrendo, entrou na casa em que estava na frente, enquanto os outros dois rapazes saíram pulando muros e fugiram. Permaneceu no local e foi rendido pelos policiais, que disseram "perdeu, perdeu". Informou para os policiais que não tinha nada a ver com os outros dois envolvidos, mas foi algemado. Em seguida, os policiais entraram na residência ao lado de onde estavam, de onde saíram com o outro conduzido e com

drogas. Desconhecia o que estava ocorrendo. Não comercializava entorpecentes, negou que tivesse drogas em seu poder. Era usuário de maconha, já respondeu processo por porte de entorpecentes (fls. 08).

O réu Maycon Antônio não se dignou em comparecer em juízo para ser interrogado, fazendo-se revel. A sua ausência não comprometeu o contexto probatório (fls. 295/296).

No interrogatório judicial, Maicon Vinicius alegou que estava trabalhando. Chegou em casa para almoçar. Enquanto a sua mãe esquentava a comida, pegou a quantia de R\$ 7,00 dela e foi buscar um refrigerante. Viu os moleques da vizinhança e parou para cumprimentá-los. Eles gritaram: "A polícia, corre". Em seguida, todos correram. Correu porque se assustou. Foi até a casa do seu amigo, a polícia entrou atrás, mas não encontraram nada em seu poder. Estava com a família do moleque, não se lembrava o nome dele. Não tinha drogas na casa onde estava, nada foi apreendido no local. Quando a polícia veio da casa de Maycon Antônio, apareceu com o flagrante. Não sabia dizer onde foi apreendido os entorpecentes, porque estava na casa ao lado, em outro imóvel. Trabalhava como motoboy.

A versão é indigna de crédito.

O experiente policial civil Emerson Pinto de Siqueira esclareceu que receberam ligação na sede da Delegacia, por meio do telefone fixo da base, denunciando uma situação de tráfico recorrente. Tratava-se de um ponto de vendas, na quadra de esportes, na Rua do Gavião, no bairro Jardim dos Lírios. O denunciante fez referência à 'biqueira da quadra'. No corpo da denúncia, a denunciante descreveu as características dos envolvidos na venda de entorpecentes de forma firme e clara, como sendo dois homens magros, altos e as vestes que trajavam. Como a denúncia era muito rica em detalhes, montaram uma equipe, composta por três policiais. Foram até o local em uma viatura descaracterizada, em um primeiro momento, apenas para conhecerem e averiguar os dados fornecidos na denúncia. Assim que os suspeitos viram a viatura descaracterizada acessando a Rua do Gavião, eles correram, sentido à Rua Perdizes. Eles realmente estavam defronte à quadra, na Rua do Gavião. As vestes que eles trajavam convergiam com as características informadas. Os implicados entraram em uma casa, numeral 90, onde escalaram o muro dos fundos. Um dos fugitivos conseguiu subir no telhado, enquanto o outro homem, Maicon Aleixo, ficou para trás na escalada e foi detido pela equipe. Como o outro envolvido conseguiu escalar o muro, fizeram uma varredura nas imediações e perceberam que ele havia pulado o muro da casa nº 90 para o imóvel vizinho, numeral 98. Ao acessarem a casa ao lado, abordaram Maycon Antônio. Indagado, ele alegou que correu porque ficou assustado com os policiais. Realizaram buscas no interior do imóvel, onde localizaram em uma espécie de gabinete, na pia da cozinha, após retirarem as gavetas, atrás do armário, uma sacola escondida. Ao abrirem a sacola, encontraram uma grande quantidade de porções de entorpecentes, com kits fechados de maconha, totalizando a quantia aproximada de mais de 160 porções de maconha. Como os dados da denúncia foram confirmados, deram voz de prisão aos acusados.

A ocorrência foi apresentada na sede da DISE, juntamente com o pouco de dinheiro localizado com os acusados e as drogas apreendidas, onde o Delegado ratificou a voz de prisão. Os acusados não confessaram, ao contrário, alegaram que não tinham nada a ver com a história e que correram de medo da polícia por não saberem o que estava acontecendo. Os acusados nada disseram sobre o encontro das drogas que estavam em seu poder, não responderam às perguntas. Não conhecia os acusados. Quando chegaram, encontraram os réus no local descrito na denúncia, na frente da quadra, local conhecido como ponto de venda de drogas. Não os viu interagindo com outras pessoas. Adailton Camargo, outro policial civil, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que receberam ligação anônima na DISE, informando que na quadra do Bairro Jardim dos Lírios, conhecida como "Biqueira da quadra", dois rapazes estavam traficando, com a descrição das respectivas características físicas (branco, alto) e suas vestimentas (bermuda jeans, camiseta vermelha e o outro de camiseta cinza e vermelha). Segundo a denúncia, as drogas eram escondidas na casa do Maycon Antônio, residente na Rua Perdizes, 98. A autoridade determinou que uma equipe fosse até o local, em viatura descaracterizada para verificar a veracidade das informações. Deslocou-se até o endereço informado, em companhia de Emerson e André. Ao se

aproximarem do local, avistaram dois rapazes, com as características informadas, que saíram da Rua do Gavião e entraram na Rua dos Perdizes. Ingressaram na casa de número 90. Foram atrás deles, Maycon Antônio estava em cima de uma cobertura de fibra. Conseguiram deter Maicon Aleixo. Em seguida, foram até o imóvel da Rua Perdizes, numeral 98, onde abordaram Maycon Antônio. Indagado, ele disse que morava naquele local, mas que não tinha drogas na casa, acaso encontrassem entorpecentes, não lhe pertenciam. Ambos os envolvidos foram revistados. Com cada um dos acusados, localizaram uma pequena quantidade de maconha. Na casa do Maycon Antônio, o policial Emerson retirou as gavetas da cozinha e achou uma sacola, contendo 161 porções de maconha, acondicionadas em embalagem ziplock, idênticas aos invólucros que os implicados portavam (pequenas embalagens ziplock, contendo substância esverdeada). Os réus foram conduzidos até a base da Delegacia, ambos foram autuados por tráfico de drogas.

O local onde foram realizadas as diligências era muito conhecido pela incidência de indivíduos, como pela rotatividade de pessoas que ali traficavam. Foi apreendida uma pequena quantia com os autuados, acreditava que a soma que ambos portavam, não totalizava a quantia de R\$ 10,00. Frequentemente, os envolvidos faziam a vazão do dinheiro para não ficarem com grandes quantias nas mãos. Não conhecia os acusados. Como a viatura descaracterizada já era conhecida, não conseguiram fazer um acompanhamento da venda da droga, não chegou a observar os acusados em contato com terceiros porque ambos correram para o interior da casa, tiveram que agir de imediato. Após a fuga, Maycon Antônio conseguiu subir e pular para a casa vizinha, enquanto Maicon Aleixo foi segurado antes dele subir na cobertura. Maicon Aleixo portava a quantia aproximada de R\$ 7,00.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal dos acusados.

A investigação, bem resumida pelos policiais civis nos depoimentos judiciais, garantido o contraditório amplo, dá conta de que após averiguação sobre a ocorrência de tráfico de drogas na chamada "Biqueira da Quadra" (quadra de esportiva de uso coletivo), na Rua dos Gaviões, avistaram os denunciados, cujas características coincidiam com as informações anteriormente recebidas.

Ao perceberem a aproximação da viatura descaracterizada, suspeitosamente tentaram fugir correndo, pulando muros de outras casas. Maicon Vinicius Aleixo foi detido enquanto buscava escalar um muro, portando uma porção de maconha e dinheiro. O acusado Maycon Antônio, por sua vez, localizado no interior de sua residência, também trazia com ele uma porção de maconha e dinheiro.

Na residência de Maycon Antônio, vizinho do local onde estava Maicon Vinicius Aleixo, foram localizadas a expressiva quantidade de 159 porções de maconha, não coincidentemente, embaladas de forma idêntica aquelas encontradas em poder deles. Também foi apreendida a quantia de R\$ 64,00 em dinheiro, ao que tudo indica, proveniente do tráfico.

Houve comprometedor fuga, os réus estavam exatamente no local apontado como de tráfico e correspondiam, nas características, àquelas informadas aos agentes da autoridade.

Levavam com ele um tanto de droga, na espécie idêntica àquela outra, maconha, apreendida na casa.

Em suma, a prova não autoriza qualquer hesitação quanto ao convencimento das responsabilidades criminais dos réus, mercê das condutas já delineadas, agindo em concurso e unidade de desígnios, previamente ajustados, praticarem crime permanente, tráfico, resumido na guarda e manutenção em depósito da droga, para o fim de traficar.

Mesmo que não houvessem sido pilhados vendendo a droga, a denúncia é certa em os acusar de guardar e manter em depósito drogas, para tráfico.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da

caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também, relembre-se e se repete, o fato de ser usuário de drogas não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga, e depoimentos de policiais.

A versão dos policiais civis, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Indiferente as alegações dos réus de que não teriam envolvimento com o tráfico, na conduta de vender o entorpecente, na medida em que a acusação é certa de imputar a eles a conduta de guardar e manter em depósito, para esse fim, drogas.

Sequer fizeram prova da versão exculpatória, como lhe incumbiam.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Note-se que o réu Maycon Antônio sequer ousou apresentar versão na única oportunidade em que foi interrogado. Fez-se revel.

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação (fls. 16/18), e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 106/108).

Fixação das penas.

O réu Maicon Vinicius Aleixo é primário. Fixo a pena base no mínimo legal, não expressiva a quantidade de drogas para exasperação com fulcro no artigo 42 da Lei de Drogas.

Na segunda fase, não existem circunstâncias para consideração.

Em terceira e última fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, provado que traficavam nas imediações de quadra de esportes. Exaspero a pena em 1/6 (um sexto).

Ainda na última fase, sem comprovação de que se dedicasse a atividade criminosa e nem integrasse organização criminosa, reduzo a pena de Maicon Vinicius Aleixo em metade, assim a tornando definitiva.

É de se impor o regime inicial aberto em relação ao réu Maicon Vinicius Aleixo, pela somatória da pena, reclusiva.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores.

Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, o regime inicial aberto, analisada a detida conduta dos autos, é de ser imposto ao condenado Maicon Vinicius Aleixo, primário.

Corréu: Na primeira fase, observo que o réu Maycon Antônio Lopes Fagundes tem maus antecedentes, com duas condenações certificadas. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (Processo nº 1504160-10.2018.8.26.0019, 2ª Vara Criminal do Foro de Americana, incurso no Art. 28 "caput" do SISNAD e Art. 329 "caput" ambos c/c Art. 61 "caput", I ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 20/11/2020). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar

'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Aumento a pena base em um sexto em relação ao acusado Maycon Antônio Lopes Fagundes, pelos maus antecedentes.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência específica (vg. Processo nº 0011319-20.2014.8.26.0019, 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 "caput" do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 30/09/2016, pena extinta em 11/05/2017). Exaspero a pena de Maycon Antônio Lopes Fagundes em mais 1/6 (um sexto).

Em terceira e última fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Exaspero a pena do réu acusado Maycon Antônio Lopes Fagundes em 1/6 (um sexto).

Impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque acusado Maycon Antônio é reincidente. E a pena final, por si, impõe óbice a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado para o acusado Maycon Antônio Lopes Fagundes, seja porque o tráfico é crime equiparado a hediondo, seja porque este é o único regime suficiente à repressão e prevenção do delito em questão, além de adequado à quantidade da pena a ser imposta.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar: a) MAICON VINICIUS ALEIXO às penas de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e noventa e um (291) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006; b) MAYCON ANTÔNIO LOPES FAGUNDES às penas de sete (07) anos, onze (11) meses e oito (08) dias de reclusão, regime inicial fechado e setecentos e noventa e três (793) dias-multa, por infração ao artigo 33, 'caput', c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, combinadas as infrações com o artigo 61, I, do Código Penal.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em relação ao acusado MAICON VINICIUS ALEIXO, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais prestação pecuniária, que arbitro em um (01) salário-mínimo.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Condeno o réu Maicon Vinicius Aleixo nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, na medida em que constituiu advogada, sem comprovação de que fosse hipossuficiente.

Isento o réu Maycon Antônio Lopes Fagundes das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 164).

Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Faculto recurso em liberdade, porque assim os réus vêm respondendo aos atos do

processo, mantidas as medidas cautelares diversas da prisão concedidas até o trânsito em julgado.
Após o trânsito, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.
P.I.C.

Americana, 20 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA